

1526206-74.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais

Magistrado: RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/04/2022

... a reprimenda a partir da pena imposta ao tráfico de drogas, sendo certo que foi este o entendimento acolhido pelo C. STJ. No específico caso concreto, em oportunidade mais recente, o C. STF também se manifestou, fixando a seguinte tese em sede de repercussão geral: "É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1526206-74.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526206-74.2020.8.26.0228 Controle nº 0984/2021

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2311224/2020 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 15202641 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 5502/20/210 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 2311224 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME DA SILVA DE LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

VISTOS.

GUILHERME DA SILVA DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 273, §1º e §1º-B, inciso I, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque, segundo narra a denúncia, no dia 14 de dezembro de 2020, em ocasião de calamidade pública, por volta das 14h00, nas dependências do estabelecimento comercial "GM Nutrição Esportiva", localizado na Avenida Celso Garcia, 5073, Tatuapé, nesta cidade e comarca da Capital/SP, vendeu e tinha em depósito produtos destinados a fins terapêuticos e medicinais adulterados, consistentes em 02 frascos de Oxadrolona, 05 frascos de Enantato de Metenolona - Primobolan, 02 frascos de sais de testosterona, 01 frasco de undecilenato de boldenona, 02 frascos de enantato de testosterona - Sustanon e 05 frascos de

decanoato de nandrolona – DECA, e ainda os produtos não adulterados, 06 frascos de acetato de trembolona, 04 frascos de enantato de testosterona e 01 caixa de comprimidos de acetato de metenolona, todos sem registro no órgão de vigilância sanitária competente – Anvisa.

A denúncia foi recebida, o réu citado. Sobreveio resposta à acusação. Em instrução, foram ouvidas testemunhas de acusação e defesa. Interrogado, o acusado negou a imputação. Nos debates, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação, enquanto a Defesa pugnou por absolvição, diante da prova produzida.

Síntese do necessário.

Relato, DECIDO.

Denúncia PROCEDENTE em parte.

Segundo restou apurado, o acusado mantinha estabelecimento comercial no qual vendia diversas substâncias esteroides e anabolizantes, sendo certo que os produtos comercializados não possuíam registro junto à Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, além de parte deles serem adulterados.

Ocorre que policiais civis em investigações relacionadas a apreensões de esteroides e anabolizantes, na data dos fatos, receberam informação privilegiada dando conta de que um motoboy realizaria a entrega das aludidas substâncias, por volta das 13h00, em frente ao restaurante “Ragazzo”, situado na Avenida Governador Carvalho Pinto, 748, neste município.

Em razão disso, os agentes policiais se deslocaram até o endereço indicado, realizando breve campana, até o momento em que avistaram o motoboy Carlos Costa Barbosa Silva chegar ao local, tendo ele as mesmas características lhe lhes foram passadas, motivo pelo qual deliberaram pela abordagem.

Com Carlos foi encontrado um pacote lacrado e sem identificação do conteúdo, cujo destinatário seria pessoa identificada tão somente pelo prenome “Éder”. Aberta a encomenda pela equipe policial, foram encontrados 01 frasco de oxandrolona, 01 frasco de trembolona e 01 frasco de testosterona. Indagado, o motoboy explicou que fora contratado como freelancer por GUILHERME, para realizar a entrega dos produtos, ainda esclarecendo que o réu possuía uma loja de nutrição esportiva, declinando o local do estabelecimento.

Os agentes policiais, então, deslocaram-se até o local indicado por Carlos, encontrando a loja “GM Nutrição Esportiva”. Lá, foram atendidos por GUILHERME que, após ser cientificado sobre o motivo das diligências, franqueou entrada aos policiais civis.

Na parte interna do estabelecimento, em um depósito, foram encontradas 01 caixa de comprimidos de metenolona acetato, 01 frasco de oxandrolona, 05 frascos de “DECA”, 05 frascos de trembolona, 02 frascos de Testosterona, 02 frascos de sustanon, 05 frascos de primabolan e 01 frasco de boldenona. Naquele mesmo local ainda foram apreendidos cinco atestados médicos em branco e diversas etiquetas de oxandrolona e stanozolo.

A materialidade e autoria restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo pericial e pela prova oral coligida.

O policial civil Anderson Tessitore disse que, no dia dos fatos, ele e outro policial, em investigações relacionadas às diversas apreensões de substâncias anabolizantes, após receberem informações privilegiadas sobre entrega de

substâncias de tal natureza por um motoboy, deliberaram por fazer campana no local indicado pelas informações, cerca de 45 minutos. Em dado momento, o motoboy foi visualizado e deliberaram pela abordagem, localizando em poder de tal pessoa, identificada com Carlos, uma sacola com três produtos. Carlos indicou que se tratava de motoboy contratado para entrega por pessoa de prenome Guilherme, indicando ainda o local onde pegou a encomenda, uma loja de suplementos. Em razão disso, foram à referida loja, onde foram atendidos pelo réu, o qual esclareceu ser o proprietário do estabelecimento. O acusado franqueou a entrada dos policiais na parte interna da loja, num cômodo na parte posterior da loja, onde encontraram diversas outras substâncias anabolizantes, cerca de 30 produtos da mesma natureza daquelas apreendidas inicialmente. Encontraram ainda receituários de um hospital da Penha, com carimbos de cinco médicos diferentes. Inquirido o acusado confirmou que vendia aquelas substâncias para “complementar a renda da loja, que estava baixa” (sic). O acusado dizia que era competidor na área de fisioculturismo, mas os produtos encontrados na loja estavam todos lacrados e havia, ainda, muitas etiquetas soltas; ademais, prosseguiu a testemunha, a quantidade de produtos apreendidos era incompatível para consumo próprio.

No mesmo sentido, em suma, o quanto narrado pelo policial civil Renan Daniel Monteiro de Oliveira.

Já a testemunha Carlos Costa Barbosa da Silva disse que trabalha como motoboy e prestava serviços eventuais para o acusado Guilherme. No dia do fato estava fazendo mais uma destas entregas e, como sempre, recebia uma mensagem dele, passava na local, retirava a encomenda e, então, a levava para o cliente. Não sabia o que havia nos pacotes, salvo quando o empacotamento se fazia na sua frente. No dia do fato o pacote já estava embalado. Raras vezes, como no dia do fato, recebia a encomenda já empacotada. Quando os policiais chegaram, de pronto indicou a origem daquele pacote.

A testemunha de defesa Thiago Moreira de Carvalho disse que faz entregas para o acusado. Costumava entregar “suplementos” para ele, de sua loja. Sempre soube que ele vendia produtos legais, “produtos que ele pegava na prateleira da loja” (sic). Não sabe se o acusado é fisioculturista.

A testemunha de defesa Elias Gustavo Lacotiche disse ser proprietário de uma farmácia de manipulação voltada para o público de atletas de “alto rendimento” (sic). Conhece o acusado de sua farmácia, inclusive porque “o apoia” em suas atividades em que compete como atleta. Ele usa alguns produtos “que precisa usar”, “tomar alguns suplementos, medicamentos”, geralmente manipulados. Então, fornece estas substâncias e, em troca, Guilherme faz publicidade de sua farmácia. Desconhece qualquer atividade ilícita por parte de Guilherme. Nunca forneceu ao réu, dentro da relação comercial, a substância enantato de metenolona, assim como não fornecia ao acusado as substâncias encontradas na loja do acusado, ao menos na forma como encontradas (frascos).

Victor Augusto de Lima Lucchesi, também testemunha de defesa, disse que ser amigo do acusado. Trabalha como nutricionista e frequentava a loja do acusado, praticamente toda semana. A loja ficava no Tatuapé. Nunca “verificou nenhum produto falsificado no local” (sic). Sabe que o réu é atleta fisioculturista, sabendo, também, do seu uso de anabolizantes. Sempre acompanhou sua carreira de atleta. Soube que o réu era patrocinado por marcas de suplementos e laboratórios.

Sebastião Pereira Marinho Filho, testemunha de defesa, disse ser amigo do acusado “de muito tempo” (sic). Sabe que ele é fisioculturista, sabendo, também, que ele utiliza anabolizantes. Não sabe se recebe tais produtos por patrocínio no mundo do fisioculturismo.

A testemunha de defesa Paulo Sérgio Oliveira Sanches disse que é amigo do acusado.

Guilherme é atleta, pelo que sabe. Ele pratica “musculação”, sendo que já competiu na categoria. Não sabe se faz uso de anabolizantes, mas acredita que sim, “pelo tamanho dele” (sic).

Interrogado, o réu disse que é atleta desde os dezessete anos, na área do fisioculturismo. Por isso, recebia patrocínios de laboratórios, recebendo anabolizantes para seu próprio uso. No dia do fato, um cliente fez uma compra grande de suplementos, na ordem de R\$700,00. Tinha em sobra anabolizantes e deu, graciosamente, para este cliente. Nunca vendeu estas substâncias. Tudo o que havia na loja era de seu uso, para fim de competição esportiva. O nome do cliente era Eder, e não tinha qualquer outra qualificação. Receberia o valor da venda em dinheiro. Todas as substâncias encontradas na sua loja foram presentes de patrocinadores. Seu patrocinador era a “Dark Pharma” e todas as substâncias apreendidas foram encaminhadas por ela. Na loja havia adesivos da “Dark Pharma”, mas não rótulos de produtos. Estes adesivos eram material promocional. Iria dar para Eder três produtos: melantato e oxidrolona (sic). Por muita insistência de Eder, acabou por dar estes produtos “de brinde” (sic). Afirmou desconhecer, por completo, a ilicitude das substâncias apreendidas em seu comércio.

Foi o que se colheu da prova oral.

A natureza das substâncias é indene de dúvidas como se extrai do laudo pericial. De fato, algumas delas poderiam ser verdadeiros placebos, como no caso dos comprimidos indicados como Oxandrolona. Todavia, outras detêm princípios ativos que integram a lista da Portaria SVS/MS n. 344/98, que trata das substâncias anabolizantes, que são, por sua vez, substâncias destinadas a fins medicinais.

A prova oral, por sua vez, indica a localização de tais substâncias em poder do réu, alguma delas, aliás, já encaminhadas para o que seriam clientes do acusado. Isso porque os policiais foram claros ao narrar a apreensão de parte das substâncias em poder de motoboy que indicou o estabelecimento do réu como origem das substâncias que seriam entregues para terceiro. No próprio estabelecimento do réu, mais substâncias foram apreendidas.

Entretanto, do coligido não restou comprovado o dolo do acusado quanto às condutas do §1º do artigo 273, do Código Penal. Afinal, os produtos apreendidos estavam rotulados em sua maioria com o nome “Dark Pharma” ou “Pharma Plix”, porém, no endereço da apreensão não se mencionou a localização de petrechos para falsificação/adulteração ou qualquer outro indicativo robusto de produção ou ciência da natureza e do princípio do ativo de cada produto. Nesse sentido, os produtos estavam embalados, ao que se extrai das fotos dos autos, sendo certo que a adulteração emergiu apenas a partir do laudo pericial. A única coisa que militaria contra o réu seria a apreensão de etiquetas com a marca “Dark Pharma”, mas insuficiente para, de forma segura, indicar a efetiva falsificação.

Assim, à míngua de circunstâncias externas que indiquem ciência quanto à adulteração, não é razoável admitir que a mera posse do produto adulterado induza ciência quando a falsificação, notadamente em caso como o dos autos. Assim de rigor a absolvição quanto a tal crime.

Contudo, tal observação não elide a responsabilização penal do acusado pela figura do artigo 273, §1º-B, inciso I, do Código Penal, do Código Penal. Aqui a solução é diversa, porque, evidentemente, o réu sabia que o produto comercializado não tinha registro.

Primeiro, porque seu próprio ramo de atuação indica que não se trata de pessoa absolutamente leiga na temática, ao contrário. Ademais, a forma como tratava os produtos também indica ciência de sua conduta ilícita, ou seja, contratava serviços de terceiros para o transporte; não identificava o produto, embalando-o de forma

discreta; e, em seu estabelecimento, armazenava os anabolizantes em local não acessível ao público, de modo que produtos não ficavam à vista da clientela ou de curiosos, medida que somente se coaduna com a ciência da ilicitude da conduta. Portanto, aqui a denúncia procede.

A propósito, cabe destacar que o preceito secundário do dispositivo em comento (art. 273, §1º-B, inciso I, do Código Penal), como costumeiramente debatido na jurisprudência, mostra-se desproporcional, embora, de fato, reprovável a conduta do agente. O flagrante descompasso entre a conduta e a pena abstratamente imposta, conduziu os aplicadores do direito a balizar a reprimenda a partir da pena imposta ao tráfico de drogas, sendo certo que foi este o entendimento acolhido pelo C. STJ. No específico caso concreto, em oportunidade mais recente, o C. STF também se manifestou, fixando a seguinte tese em sede de repercussão geral: "É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica reprimido o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)".

Observo finalmente que, havendo tipo específico, não se deve falar em aplicação analógica da Lei de Drogas (Lei n. 11.343/2006).

Por tais razões, a denúncia procede parcialmente.

Passo à fixação das penas.

Na primeira fase da dosimetria as penas devem ser fixadas acima do mínimo indicado para a espécie, observado o supra e retro indicado.

Isso porque, primeiro, foram três as substâncias sem registro encontradas em poder do acusado, o que representa maior gravame à saúde pública. Depois, porque o acusado agia mediante forte estruturação, com comércio regularmente estabelecido, dando aparência de regularidade para a atividade ilícita, contando, inclusive, com colaboradores para entrega em domicílios, de forma a transparecer, com evidência, que sua atividade era contínua.

Isso posto, as penas iniciais partem de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, mínimos.

Na segunda fase da dosimetria, cabível, ainda, a incidência do agravamento da pena em razão da calamidade pública, uma vez que o delito fora praticado em meio à pandemia ocasionada pelo COVID.

E, no ponto, descabe falar que a conduta em nada fora afetada, ou que ela nada afetou, o mundo fenomênico. Absolutamente. Primeiro porque, como cediço, situações de calamidade pública trazem sempre a necessidade de readequação dos equipamentos públicos governamentais, direcionando-os ao combate, no caso, da pandemia. Isso significa diminuição de vigilância, maiores gastos com o atendimento das demandas urgentes e, por efeito direto, menor poder de polícia do Estado. Depois, porque todo prejuízo suportado pelo Estado, nestas excepcionais circunstâncias, representa maior gravame, diante da escassez de recursos decorrente da queda da atividade econômica, fato público e notório, a independer de prova.

Ademais, como se extrai da doutrina, "essa agravante genérica justifica-se pela insensibilidade moral do agente, que não observa os mais mezinhos postulados de fraternidade e de solidariedade humana e se aproveita de situações calamitosas ou de desgraça particular da vítima, que se encontra em posição de inferioridade, para praticar um crime". Também, nesse sentido, o escólio de Rogério Sanches Cunha.

Assim, de forma alguma estamos diante de uma situação de responsabilidade penal objetiva.

Portanto, agravo sua pena para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, mínimos.

Ausentes outras razões modificativas, torno-as definitivas em tais termos.

Presentes os pressupostos legais, SUBSTITUO a pena corporal, nos termos do artigo 44 e seguintes do Código Penal, por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena restritiva de liberdade, e por pena de multa, na mesma quantidade e com o mesmo valor e forma de correção da pena de multa originária.

Em caso de descumprimento, o regime inicial de desconto da pena corporal será aquele aberto.

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR o réu GUILHERME DA SILVA DE LIMA, qualificado nos autos, às penas de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, substituída a pena corporal nos termos deste julgado, mais pagamento de 15 (quinze) dias-multa, mínimos, por incurso nas penas do artigo 273, §1º-B, inciso I, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, bem como para ABSOLVÊ-LO da imputação do artigo 273, §1º, do Código Penal.

O réu respondeu solto. Faculto recorra da mesma forma.

Quanto aos produtos apreendidos, encaminhem-se para a destruição, independentemente do trânsito em julgado.

P.R.I.C.

São Paulo, 06 de abril de 2022.

RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA